دار المنظومة
DAR ALMANDUMAH
الرواد في قواعد المعلومات العربية

العنوان:	توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية : الإشكالات والحلول والمقترحة
المصدر:	منشورات مجلة الحقوق - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر:	محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي:	الطالب، عبدالكريم
المجلد/العدد:	ع1
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2009
الصفحات:	77 - 96
رقم MD:	590853
نوع المحتوى:	بحوث المؤتمرات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	IslamicInfo
مواضيع:	توزيع الاختصاص، الاختصاص القضائي، المحاكم الابتدائية، المحاكم التجارية، المغرب
رابط:	https://search.mandumah.com/Record/590853

© 2019 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر، علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط، ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية : الإشكالات والحلول المقترحة

الدكتور عبد الكريم الطالب
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بمراكش

إن المتتبع لموقف المشرع المغربي فيما يتعلق بالإختصاص في المادة التجارية قد يلاحظ تردده بين تمتيع المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة والاختصاص المدني عامة بصلاحية البت في بعض القضايا ذات الطابع التجاري التي تدخل عادة في صميم صلاحية المحاكم التجارية المحدثة في 12 فبراير 1997 وبين منعها من النظر البتة في كل ما يندرج ضمن مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة.

وإذا كان إحداث المحاكم التجارية يرمي إلى خلق قضاء متخصص في المجال التجاري من جهة وإلى إبراز الخصوصيات التي تتميز بها القضايا التجارية من سرعة وبساطة وثقة بين التجار من جهة أخرى، فإن الواقع أفرز عدة إشكالات تتمثل في عموم وغموض الألفاظ المستعملة في قانون المحاكم التجارية وهو ينظم اختصاصها والإجراءات أمامها، الأمر الذي ضغط على المشرع المغربي ليعدل المقتضيات التي فصلت بشكل قطعي بين اختصاص المحاكم الابتدائية – المدني– واختصاص المحاكم الجديدة –التجاري– لينص سنة 2002 على فتح الباب أمام المحاكم الابتدائية كمحكمة للموضوع وكمؤسسة للرئيس لتبت في المادة التجارية بشروط وضوابط يتعين احترامها.

وعلى الرغم من إيجابيات هذه الأحكام الجديدة، فإن إشكالات أخرى طفت على السطح، وأفرزت الممارسة العملية كثيرا من الصعوبات على مستوى الإجراءات والمسطرة خصوصا.

ومحاولة منا في إبراز مختلف هذه الإشكالات، واقتراح الحلول الممكنة لتجاوزها سنعمد إلى تقسيم الموضوع وفق التصميم التالي :

أولا : إشكالات توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية على مستوى الموضوع والحلول المقترحة،

ثانيا : إشكالات توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية على مستوى المسطرة والحلول المقترحة.

أولا : إشكالات توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية على مستوى الموضوع والحلول المقترحة

1 – كراء المحلات التجارية

نصت المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية على الاختصاص النوعي لهذه المحاكم إذ تنظر في القضايا التالية:

"1 – الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية،

2 – الدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية،

3 – الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية،

4 – الدعوي الناشئة بين شركاء في شركة تجارية،

5 – النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير".

ويعتبر الاختصاص في مادة الأصول التجارية من الإشكالات التي يثيرها توزيع الاختصاص بين هذه المحاكم والمحاكم الابتدائية رغم أن قضاء المجلس الأعلى أكد في أكثر من قرار أن النظر في هذا النوع من القضايا يرجع إلى المحاكم التجارية وهو ما يعتبر في تقديرنا محلا للنقاش.

وإلماما بهذا الإشكال نرى من المفيد أن نذكر بالمراحل التي قطعها العمل القضائي قبل أن يقول المجلس الأعلى كلمته فيه[1].

---

1 - خلافا لأغلب القوانين المقارنة عمد المشرع المغربي في مدونة التجارة (قانون 95-53) الصادرة في فاتح غشت 1996 إلى أن : "الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقول المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية".

والحقيقة أن مسألة وضع التعاريف من اختصاص الفقه لا التشريع، ومن ثم كان موقف مشرعنا مشوبا بنوع من الخروج عن القاعدة المعمول بها في هذا الإطار.

الاتجاه الأول : المحاكم التجارية ليست مختصة بالنظر في كراء المحلات التجارية التي يكون الأصل التجاري موضوعا لاستغلاله :

ينتسب لهذا الاتجاه جل المحاكم التجارية بالمملكة، ومحكمة الاستئناف التجارية بفاس واحدة منها حيث جاء في إحدى حيثيات من قراراتها : "وحيث إن المشرع وبمقتضى قانون 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية وإن خول السيد رئيس المحكمة التجارية نفس الصلاحية التي كانت مسندة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية إلا أنه لم يتعداها للاختصاصات التي كان يبت فيها السيد الرئيس ولا المحكمة بمقتضى قوانين خاصة، ومنها ظهير 24-05-1955 علما بأن مقتضيات الظهير المذكور لاتدخل في زمرة القضايا المنصوص عليها بمدونة التجارة، ودفع المستأنف بأن الأمر يتعلق بالمنازعة في الأصل التجاري، والمشرع في قانون إحداث المحاكم التجارية لم يحدد المسائل المتعلقة بالأصل التجاري دفع مردود إذ أن الأمر أصلا يتعلق بإنهاء عقد تجاري وإن كان يؤول إلى إفراغ الأصل التجاري، ثم إن المنازعات المتعلقة بالأصل التجاري وخلافا لما ورد بالمقال الاستئنافي محددة على سبيل الحصر بمدونة التجارة، إذ اقتصر فيها المشرع على بيع الأصل التجاري أو تقديمه حصة في شركة أو رهنه أو التسيير الحر له دون إمكانية إدخال النزاعات الناتجة عن تطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955".

الاتجاه الثاني : المحاكم التجارية مختصة بالبت في كراء المحلات التجارية التي يكون الأصل التجاري موضوعا لها.

يتزعم هذا الاتجاه محكمة الاستئناف التجارية بمراكش التي استندت لتأييد موقفها إلى الصياغة العامة التي وردت بها الفقرة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية لمنح الاختصاص لها.

ومما جاء في أحد قراراتها :

"إن لفظ النزاعات الواردة في الفقرة المذكورة جاءت شاملة لجميع النزاعات سواء تعلق الأمر بالعقود المنصبة على الأصل التجاري أو المنازعات الرامية إلى رفض أو تجديد العقود في إطار ظهير 24 مايو 1955 أو غيرها من المنازعات

الأخرى وسواء تعلق بنزاع حول الأصل التجاري برمته أو بأحد عناصره إذ أن مناط اختصاص المحاكم التجارية هو وجود نزاع يتعلق بالأصل التجاري بصرف النظر عن العقد مدنيا أو تجاريا"[1].

و في نفس الاتجاه، ورد في قرار آخر لنفس المحكمة ما يلي :

"وحيث إنه بالرجوع إلى الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 95- 53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية يتضح بأنه يسند الاختصاص للمحاكم التجارية للبت في المنازعات المتعلقة برئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المسندة إليه بنصوص خاصة والتي لها ارتباط بالنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية بوصفه جزءا من هذه المحكمة، فإنه مختصا بالبت في مراجعة الوجيبة الكرائية في إطار ظهير 5 يناير 1953 باعتبار أن مراجعة هذه الوجيبة من شأنها التأثير في قيمة الأصل التجاري إيجابيا أو سلبيا، وباعتبار أن الحق في الكراء يعتبر عنصرا أساسيا في تكون الأصل التجاري"[2].

الاتجاه الثالث : الاختصاص في كراء المحلات التي يكون موضوعها الأصل التجاري ممنوح للمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية :

ينبني هذا الاتجاه على طبيعة عقد الكراء، فإن كان تجاريا وأبرمه طرفان تاجران، فإن الاختصاص منوط بالمحاكم التجارية. أما إذا لم يكن العقد

---

1 - قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 105\98 الملف عدد 107\98 الصادر بتاريخ 21\10\1998، منشور بمجلة المحامي، هيأة المحامين بمراكش ، العدد 34، يناير 1999، ص 198 وما بعدها.

2 - قرار رقم 146 ملف عدد 156\98 صادر بتاريخ 17 نونبر 1998 .

ومع ذلك فإن قرارا لنفس المحكمة سار على خلاف هذا المنحى، إذ رفض منح الاختصاص للمحاكم التجارية في مادة مراجعة الوجيبة الكرائية .انظر قرارها رقم 154\98 ملف عدد 321\98 الصادر بتاريخ 05\10\1998 منشور بمجلة المنتدى يصدرها منتدى البحث القانوني بمراكش، العدد الأول، أكتوبر 1999، ص 239-241.

ذا طبيعة تجارية ولم يبرمه أطراف يكتسبون صفة "التاجر"، فالبت فيه يعود للمحاكم الابتدائية.

وتأكيدا على هذين الموقفين نورد بعض الحيثيات التي جاءت في بعض الأحكام، فقد ورد في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-06-1998 :

"إن عقد الكراء لم يذكر ضمن العقود التجارية المنظمة بمدونة التجارة. يضاف إلى ذلك أنه لا يعتبر عملا تجاريا بالطبيعة إلا إذا أبرم بين تاجرين وهي الحالة التي تكون من اختصاص المحاكم التجارية تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة..."[1].

ومما ورد في حكم استعجالي عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24\06\1998 : "حيث إن الطلب يرمي إلى إجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955، وحيث يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية. وحيث تختص المحاكم التجارية بحسب اختصاصها النوعي بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية والتي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والمتعلقة بالأوراق التجارية و الناشئة بين شركاء في شركة تجارية، والمتعلقة بالأصول التجارية، وحيث إن طلب إجراء الصلح في إطار الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 يهم النزاع بخصوص المحل المعد للتجارة، الشيء الذي يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بالإضافة إلى ذلك أن الاختصاص بشأن محاولة الصلح يرجع حسب مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 إلى السيد

1 - الملف عدد 98\2 منشور بمجلة الحدث القانوني، العدد 8 \ شتنبر 1998 ص7. انظر في نفس الاتجاه قرار نفس المحكمة بتاريخ 26\08\1999.

رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضي الصلح مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي لقاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية"[1].

ونعتقد أن هذا التضارب في المواقف ما كان ليحصل ويتأجج لولا الخلط الذي وقع بخصوص التمييز بين كراء الأصل التجاري كعناصر منقولة ومعنوية مخصصة لممارسة نشاط تجاري، وبين كراء المحل التجاري الذي يستغل ويسير فيه هذا الأصل.

وفي رأينا المتواضع يبقى الاتجاه الأول هو الأقرب إلى الصواب رغم أن قضاء المجلس الأعلى سار في الاتجاه المخالف وذلك لعدة اعتبارات منها :

1 – يتبين من خلال التسمية التي آثر مشرعنا أن يعطيها لهذا الظهير ومن خلال فصله الأول أن الأمر لا يتعلق بكراء الأصل التجاري وإنما بكراء العقار الذي يستغل فيه، ومن ثم ينبغي التمييز بين كراء الأصل التجاري المعروف بالتسيير الحر والمنظم في مدونة التجارة من المادة 152 إلى 158 وبين كراء العقار أو المحل المعد للاستعمال التجاري الذي يخضع لمبادئ وقواعد القانون المدني،

2 – لا يعد كراء العقار عملا تجاريا وبالتالي لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، أما كراء الأصل التجاري فهو عقد تجاري ويندرج في أحكام المادة الخامسة من القانون 95-53، ولما كان كراء العقار عملا مدنيا باستعمال

---

1 - الملف الاستعجالي رقم 98\7 منشور بمجلة الإشعاع، هيأة المحامين بالقنيطرة، العدد السابع عشر، يوليوز 1998، ص 225.

لمزيد من المعلومات حول هذه المواقف راجع :

- المهدي شبو، محاولة في تأصيل الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية على ضوء المادة الخامسة من القانون رقم 95-53. منشور بمجلة المنتدى، مرجع سابق، نفس العدد، ص 78-99.

- بوعبيد عباسي، تضارب الاجتهاد القضائي التجاري بشأن الاختصاص في مادة الكراء التجاري (ظ 24 ماي 1955) منشور بنفس المجلة ص 162-198.

- أحمد الخزامي، الاختصاص النوعي ومدى حدوده، منشور بمجلة "المحامون" تصدرها هيأة المحامين بآسفي، العدد 6، السنة 1998، ص 249-255.

مفهوم المخالفة لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة السادسة من مدونة التجارة التي تنص على أن شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها يعد عملا تجاريا ما دام أن المشرع اقتصر في إضفائه للطابع التجاري على شراء العقارات دون إكرائها أو اكترائها، فإنه يبقى الكراء المنظم بمقتضى ظهير 24 ماي 1955 خاضعا لاختصاص المحاكم الابتدائية،

3 – لا يسبغ كراء المحل ولو للاستعمال التجاري على المكري أو المكتري صفة التاجر، ما لم يتم اكتسابها للأسباب الأخرى الواردة في مدونة التجارة،

4 – إن المنازعات المقصودة في المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية لا تتعلق بالمحلات أو العقارات التي تستغل فيها الأصول التجارية، وإنما يراد بها تلك التي تنصب على الأصول التجارية بعينها، كالمنازعة في شكليات إبرامها، أو في شروط قيامها أو في إبطالها أو في فسخها.....،

5 – يقتضي مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين منح الاختصاص للمحاكم الابتدائية المنتشرة بشكل واسع في مختلف أرجاء المملكة على خلاف المحاكم التجارية محدودة الانتشار. فلا يعقل أن ينتقل شخص يقيم بمدينة الداخلة إلى المحكمة التجارية بأكادير – هذا ما لم يجبر على التنقل إلى مراكش حيث مقر محكمة الاستئناف التجارية – من أجل نزاع يتعلق بمحل تجاري بالنظر إلى المصاريف الإضافية والنفقات الزائدة التي سيضطر المتقاضي إلى تحملها، هذا فضلا عن الوقت الذي ستتطلبه الإجراءات للنظر في ذلك النزاع.

فالأوفق في اعتقادنا ووفق العقل والمنطق، أن يمنح الاختصاص للمحاكم الابتدائية للبت في قضايا المحلات المعدة للاستعمال التجاري،

6 – على الرغم من أن الحق في الكراء عنصر من عناصر الأصل التجاري، فإن تقريره من قبل المشرع يهدف حماية المكتري للمحل الذي استمر عقده أربع سنوات إن كان شفويا أوسنتين إن كان مكتوبا، إذ ليس من المنطقي أن

نفرغ المكتري دون أن نمكنه من التعويض المناسب والمتناسب مع قيمة المحل المكترى.

وأيا كان الأمر، فالحق في الكراء ناتج عن عقد الكراء ومتفرع عنه، ومن ثم فما دام العقد الأصلي مدنيا وخاضعا لاختصاص المحاكم الابتدائية، فإن العقل يفرض أن تنظر نفس المحاكم في الحق في الكراء أيضا كحق سببه العقد الأصلي. هذا طبعا دون الإخلال بقواعد الاختصاص المتعلق بالمحاكم التجارية متى تعلق الأمر بتفويت الحق في الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري، وفي هذه الحالة يعود الاختصاص للمحاكم التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالعقود التجارية، لا بناء على الفقرة الخامسة الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، وذلك لأن التفويت والحالة هذه عقد تجاري صرف لا علاقة له بكراء الأصل التجاري.

2 – الإنذار العقاري :

على غرار كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري، لم تسلم مسألة الإنذار العقاري من نفس التضارب في الموقف على مستوى العمل القضائي خاصة بعد إحداث المحاكم التجارية سنة 1997 وهكذا اختلفت الاتجاهات بهذا الخصوص وذلك على الشكل التالي :

– <u>الاتجاه المؤيد لاختصاص المحاكم الابتدائية :</u>

دأب عدد غير يسير من رؤساء المحاكم الابتدائية على استمرار نظرهم في الإنذارات العقارية دون اكتراث بإحداث المحاكم التجارية التي قد يؤول إليها هذا الاختصاص. ويؤكدون موقفهم بتعليل مواقفهم بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصول الواردة في القانون العقاري بظهيريه لـ 1913 ولـ 1915 [1].

---

1 – قرار رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 11 نونبر1983 ملف عقود مختلفة عدد 98\1809.

انظر في نفس الاتجاه :

قرار رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 19 مارس 1999 ملف عقود مختلفة عدد 99\1807.

- الاتجاه المناصر لاختصاص المحاكم التجارية :

قبل أن تصدر مدونة التجارة وقانون المحاكم التجارية على التوالي سنتي 1996 و1997 كانت المحاكم الابتدائية تصرح بعدم اختصاصها بالبت في طلبات توجيه الإنذار العقاري معللة ذلك بما يلي :

"وحيث تبين من المرفقات أن الأمر يتعلق بعقد قرض يكتسي الصبغة التجارية ويعود الاختصاص بشأنه إلى المحكمة التجارية"[1]

ولم تخرج بعض المحاكم التجارية عن هذا المنحى إذ أكدت أن النظر في الإنذارات العقارية يرجع إلى إليها مستندة في ذلك تارة إلى صفة التاجر وتارة إلى طبيعة المعاملة والعقد الرابط بين الطرفين.

وقد صرحت المحكمة التجارية بهذا التوجه في قرار صادر عنها بتاريخ 19\6\1998 حيث أكدت أن الاختصاص في توجيه الإنذارات العقارية من صلاحيات المحاكم التجارية[2].

- الاتجاه المختلط الذي يمنح الاختصاص للمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية على حد سواء :

في نظر هذا الاتجاه ينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية أو للمحكمة التجارية بحسب تاريخ العقد أو بصفة الأطراف.

وهكذا جاء في حكم للمحكمة التجارية بمراكش ما يلي :

"وحيث تبين من خلال فحص الوثائق المرفقة بالمقال أن أحد الأطراف لا يعتبر تاجرا و بالتالي يبقى الاختصاص غير منعقد لهذه المحكمة ولرئيسها

---

1 – المحكمة الابتدائية بمراكش حكم عدد 4416\98 بتاريخ 10\6\1998 ملف عقود مختلفة عدد 4416.

2 – حكم المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 19\6\1998 ملف عقود مختلفة عدد 255\98 منشور بمجلة الإشعاع، العدد السابع عشر، ص 250.

وهو يبت في إطار مقتضيات الفصل 20 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والفصل 148 من قانون المسطرة المدنية "[1].

ثانيا : إشكالات توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية على مستوى المسطرة والحلول المقترحة

1 – مسطرة الأمر بالأداء

تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من قانون المحاكم التجارية الصادر في فبراير 1997، يختص رئيس المحكمة التجارية بالبت في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية والسندات الرسمية وذلك وفق ما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية التي تعد الشريعة العامة في المادة المسطرية.

ولا حاجة للتذكير بالجدل الحاد الذي أثارته هذه المادة قبل أن تعدل في 13 يونيو 2002 لا سيما في مسألة الفصل بين اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة التجارية ،إذ تم تفسير الأحكام المومأ إليها أعلاه بصورة تجعل اختصاص رئيس المحكمة التجارية مقتصرا على الأوراق التجارية (الشيك والكمبيالة والسند لأمر) وكذا على السندات الرسمية التي يحررها أشخاص مؤهلون لممارسة مهمة تحرير وتوثيق العقود (العدول والموثقون)، أي أنه لا يمكنه أن ينظر في الأوراق الأخرى الخارجة عن دائرة الأوراق التجارية، كما أنه لا يملك صلاحية البت في السندات العرفية التي أبقاها المشرع تحت صلاحية رئيس المحكمة الابتدائية صاحب الولاية العامة في المساطر الرئاسية.

---

1 – حكم المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 31\12\1998.

انظر كذلك حكم نفس المحكمة بتاريخ 23\6\1998.

ولمزيد من التوسع في مختلف المواقف والنقاشات بخصوص الإنذار العقاري انظر:

نور الدين الجزولي، الإنذار العقاري وتضارب الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والتجارية بشأنه، مجلة المنتدى، العدد الأول، مرجع سابق، ص 37-58

وغني عن البيان أن هذا الوضع لم يكن ليحقق توحيد العمل والاجتهاد القضائيين، وذلك لتضارب المواقف وتباين الاتجاهات وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين ويزعزع الثقة التي من المفروض أن يحظى بها القضاء.

نتيجة لهذه السلبيات، لم يتأخر المشرع المغربي عن الاستجابة للنداءات المتكررة التي رفعها الفقهاء والقضاة على حد سواء،حيث عمد في 2002\06\13 إلى تعديل المادة 22 لتمنح الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية والسندات الرسمية لكن شريطة أن يتجاوز مبلغ النزاع 20000 درهم[1].

ومن حسنات التعديل المذكور، حسم النقاش الذي كان قائما بشأن الحدود الفاصلة بين اختصاص رئيس المحكمة التجارية وذلك الممنوح لرئيس المحكمة الابتدائية إذ أكد أن هذا الأخير يمكنه النظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية شريطة ألا تتجاوز قيمتها 20000 درهم. وهو الشيء الذي بموجبه أضحى رئيس المحكمة الابتدائية يتمتع بصلاحية البت في القضايا التجارية وهو الأمر الذي لم يكن موكولا إليه صراحة في ظل النص القديم الذي يعود إلى 1997.

والحقيقة أنه على الرغم من الإيجابيات التي يمكن تسجيلها بخصوص التعديل الجديد، فإن العديد من المآخذ يمكن إبداؤها نذكر منها :

- إن محافظة المشرع على نفس الصياغة التي اعتمدها في النص الأصلي مع إضافة العبارة المحددة لمبلغ 20000 درهم جعل الملاحظات والانتقادات ذاتها التي كان يوجهها المهتمون للنص السابق، وهو ما لم يعط أية أهمية للتعديل الجديد الذي تم إدخاله على نص المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

1 – وقد تم التعديل بمقتضى القانون رقم 02-18 الظهير الشريف رقم 108-02-1 المتمم للقانون 95-53 المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 5029 بتاريخ 12 غشت 2002.

والواقع أن الإشكالات المطروحة لا تزال قائمة رغم تعديل المادة، ذلك أن الصياغة الحالية لا تزال تحتفظ باقتصار صلاحية رئيس المحكمة التجارية على النظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية وخاصة على السندات الرسمية. وهذا يثير تساؤلا أساسيا مؤداه مدى اختصاصه بالبت في السندات العرفية التجارية. بمعنى آخر، هل يعود الاختصاص في هذا النوع من السندات لرئيس المحكمة الابتدائية دون غيره ؟ أم أن المقصود في نظر المشرع توزيع الاختصاص بين الرئيسين باعتماد النصاب الذي يمكن اعتباره فيصلا بين اختصاص كل منهما بصرف النظر عن طبيعة السندات هل هي رسمية أم عرفية ؟

- في حقيقة الأمر غموض المادة يجعلنا نقول أن رئيس المحكمة التجارية لا مكنة له ليبت في السندات العرفية ما دام المشرع لا يمنحه الاختصاص المطلق للبت في السندات الرسمية على اعتبار أن نظره في هذه الأخيرة متوقف على أن تكون قيمتها أكثر من عشرين ألف درهم. وحبذا لو قام المشرع بحذف لفظ الرسمية الذي أردفه للفظ السندات ،إذ بهذا الحذف سيكون الاختصاص موزعا بشكل واضح بين رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة التجارية.

- يترتب على الغموض الذي أشرنا إليه أعلاه التضارب بشأن القواعد الإجرائية التي ينبغي اتباعها. ذلك أن منح الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية سيرتب تطبيق أحكام قانون المسطرة المدنية، في حين سيقتضي الأمر الاحتكام إلى القواعد الخاصة المنصوص عليها في قانون المحاكم التجارية.

فحسب الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون المحاكم التجارية "...في هذه الحالة وخلافا لمقتضيات الفصلين 161 و162 من قانون المسطرة المدنية، لا يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة.

غير أنه يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية أن توقف التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل."

فإذا سلمنا بأن الاختصاص في السندات العرفية يعود لرئيس المحكمة التجارية لكان ضروريا الخروج عن المبدأ المعروف في المادة الإجرائية المدنية بخصوص أثر الاستئناف وتطبيق أحكام قانون المحاكم التجارية وذلك بعدم ترتيب استئناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية لإيقاف التنفيذ ما لم تقدر محكمة الاستئناف خلاف ذلك.أما إذا تبنينا الموقف المخالف والقاضي بمنح الصلاحية لرئيس المحكمة الابتدائية لكنا ملزمين بالرجوع إلى القواعد المدنية التي بموجبها يتوقف تنفيذ الأحكام والأوامر بمجرد ممارسة الاستئناف.

2 – قضاء الأمور المستعجلة

ينص الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية على أنه :

"يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا ،بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق (أي الفصل 148) والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.

إذا كان عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول..."

وتقضي المادة 21 من قانون المحاكم التجارية بأنه :

"يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول.

يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق – رغم وجود منازعة جدية – أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع".

انطلاقا من النصين أعلاه يتبين للوهلة الأولى أنهما يكادان يتطابقان لا سيما أنه من الضروري الالتزام بشروط القضاء الاستعجالي المتمثلة في عنصر الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق[1].

لكن بالتعمق فيهما يظهر أن ثمة بونا شاسعا بينهما وذلك من عدة نواح منها :

– أسند المشرع الاختصاص في المادة الاستعجالية لرئيس المحكمة التجارية وحده دون غيره وذلك على خلاف قانون المسطرة المدنية الذي وإن أعطى الصلاحية لرئيس المحكمة الابتدائية إلا أنه سمح لأقدم القضاة بممارسة هذا الاختصاص نيابة عن الرئيس.

---

1 – لمزيد من التوسع في القضاء المستعجل راجع :

– عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1998 ص 12 وما يليها.

– عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الخامسة \مارس2008 ص 103-141.

– محمد عبد اللطيف، القضاء المستعجل، دار النهضة العربية مصر، الطبعة الرابعة 1977، الفقرة 67، ص 83 وما بعدها.

وفي اعتقادنا فإن هذا الإغفال سيخلق الكثير من المشاكل على المستوى العملي، حيث سيطعن كل شخص في ما قد يصدره أقدم القضاة بالمحكمة التجارية بصفته نائبا عن الرئيس وبصفته قاضيا للأمور المستعجلة استنادا إلى غياب نص صريح يمنح هذا الاختصاص لأقدم القضاة.

منح المشرع للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية على غرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف البت في القضايا الاستعجالية كلما كان النزاع معروضا على محكمته. ولا شك أن الصياغة المعتمدة في القانونين (المسطرة المدنية والمحاكم التجارية) تنطوي على الكثير من المخاطر بالنسبة لحقوق المتقاضين، إذ سيرفض بعضهم أن يبت في ملفاتهم نواب الرؤساء الأولين بصفتهم قضاة للأمور المستعجلة. وسيعضدون موقفهم بغياب نص صريح يعطي الصلاحية لهؤلاء مادام أن النصين يقتصران في منح البت في القضايا المستعجلة على الرؤساء الأولين وحدهم،

– على مستوى الصياغة، نجد أن المادة 21 .من قانون المحاكم التجارية تنطوي على بعض الاضطراب. فبعد أن انتهى المشرع من تعداد اختصاص رئيس المحكمة التجارية وانتقل إلى تنظيم اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية يعود من جديد لتناول بعض التطبيقات التي يختص بالنظر فيها رئيس المحكمة التجارية وحده دون الرئيس الأول. والأولى أن ينظم اختصاص رئيس محكمة الدرجة الأولى قبل أن ينتقل إلى تبيان صلاحيات الرئيس الأول،

– عمد المشرع في الفقرة الأخيرة إلى تعداد بعض الحالات التي يختص رئيس المحكمة التجارية بالبت فيها وحده شأن الأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع،كما لو أنه يرمي إلى حصر تدخل الرئيس في المجالات المحددة سلفا. والحال أن المنطق والانسجام اللازم بين مختلف

النصوص المنظمة لنفس المسائل يفرضان أن يسند الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية في كل المسائل التي أناطها المشرع برئيس المحكمة وذلك تطبيقا للمادة 20 التي تمتع رئيس المحكمة التجارية بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس المحكمة الابتدائية كمبدأ عام.

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة اختلافا آخر بين قانون المسطرة المدنية وقانون المحاكم التجارية في المادة الاستعجالية، ذلك أن من شروط القضاء الاستعجالي في المادة المدنية ألا يمس القاضي بجدية أو جوهر النزاع، في حين عمد المشرع في المادة التجارية إلى تقرير استثناء مفاده السماح للقاضي الاستعجالي التجاري بالبت رغم وجود منازعة جدية وهذا ربما الهدف منه وضع قواعد خاصة بالمادة التجارية.

3 – الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية وآثاره

ينص الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية على أنه :

"تختص المحاكم الابتدائية – مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكم الجماعات وحكام المقاطعات – بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.

تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى".

وحسب المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية فإن هذه الأخيرة تختص بالنظر في :

"1 – الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية،

2 – الدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة أعمالهم التجارية،

3 – الدعوي المتعلقة بالأوراق التجارية،

4 – النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية،

5 – النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية".

وتقضي المادة السادسة من نفس القانون المعدلة بأن المحاكم التجارية تبت ابتدائيا في القضايا التي يتجاوز مبلغها 20000 درهم.

يظهر من هذه الفصول أن المشرع فصل بين اختصاص المحاكم الابتدائية واختصاص المحاكم التجارية، إذ تنظر الأولى في كل القضايا المدنية باستثناء ما أصبح منوطا بمحاكم أخرى بنص صريح للقانون، كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الإدارية التي أحدثت في العاشر من شتنبر 1993 وكذا المحاكم التجارية التي تم إنشاؤها في 12 فبراير1997.

بيد أن القانون المحدث للمحاكم التجارية المذكور أبى في بداية صدوره إلا أن ينتهج نفس النهج الذي سلكه قانون المسطرة المدنية وذلك بتمييزه بين الأحكام التجارية الصادرة ابتدائيا وانتهائيا وبين تلك الصادرة ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف. غير أن الفرق بين القاعدتين هو القيمة المحددة تشريعا. فالقضايا المدنية ترتكز إلى مبلغ 3000 درهم طبقا للفصل 19 من قانون المسطرة المدنية في الوقت الذي حدد المشرع التجاري مبلغ 9000 درهم للقضايا ذات الطابع التجاري.

لكن بحلول 13 يونيو 2002 عدل المشرع عن القاعدة التي استلهمت من المادة المدنية وذلك بإلغائه الاختصاص القيمي حيث أضحت المحاكم التجارية تنظر في كل القضايا التي تدخل نوعيا في اختصاصها وفق المادة الخامسة المذكورة أعلاه وتكون كل أحكامها قابلة للاستئناف ولا يتصور صدور أحكام انتهائية عن المحاكم التجارية (محاكم الدرجة الأولى).

والمتمعن في هذا التعديل سيجد له ما يبرره. فمنح الاختصاص للمحاكم الابتدائية في المادة التجارية بعد سلبها إياه في الفترة الممتدة بين 1997 و2002

يفرض بالضرورة أن تكون الأحكام التجارية الصادرة عن المحاكم التجارية قابلة دائما للاستئناف نظرا لارتفاع قيمتها مقارنة مع القضايا المدنية.

وعلى الرغم من الفوائد التي يمكن الاعتراف بها للتعديل الجديد، يبقى في نظرنا يحمل الكثير من الصعوبات منها :

- لما منح المشرع للمحاكم الابتدائية صلاحية النظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 20000 درهم يكون قد أبقى على عدة تساؤلات قائمة أهمها يكمن في القواعد الإجرائية الواجبة الاتباع في القضايا التي تنظر فيها المحاكم الابتدائية في المادة التجارية، هل هي قواعد قانون المسطرة المدنية لا سيما الفصل 19 ؟ أم هي القواعد المنصوص عليها في قانون المحاكم التجارية ؟

إن المنطق القانوني يقتضي الاحتكام إلى القواعد المدنية أولا لأن المشرع أعطى للمحاكم الابتدائية النظر في مثل هذه القضايا دون منازع، وثانيا لأن من شأن تطبيق القواعد التجارية الخاصة الوقوع في التضارب من ناحية وإفراغ الصلاحية الموكولة للمحاكم الابتدائية من أية أهمية. ومن ثم نعتقد أن قانون المسطرة المدنية هو الذي يتعين تطبيقه. وهكذا تطبق القواعد المنصوص عليها في الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية، إذ تكون الأحكام الصادرة في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 3000 درهم ابتدائية وانتهائية إسوة بالأحكام المدنية، وتكون الأحكام التي أصدرتها المحاكم الابتدائية في القضايا التجارية المتجاوزة لـ 3000 درهم وغير المتجاوزة لمبلغ 20000 درهم.

من جانب آخر، وانسجاما مع نفس الطرح، هل يطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في المادة التجارية أمام محاكم الاستئناف أم أمام محاكم الاستئناف التجارية ؟

في حقيقة الأمر، قد يقول قائل ما الجدوى من طرح هذا التساؤل علما أن العمل القضائي سار على الطعن أمام محكمة الاستئناف. الواقع أن التساؤل الذي عرضناه للنقاش له ما يبرره.

فقد يقوم بعض الأطراف بالطعن أمام محاكم الاستئناف التجارية بناء على كونها محاكم الدرجة الثانية في القضايا التجارية بصرف النظر عن الجهة التي تكون أصدرت الحكم.

لكن وحتى نحاول التأصيل للمسألة، فإن الاختصاص في الطعون الموجهة ضد الأحكام التجارية الصادرة عن المحاكم الابتدائية يرجع إلى محاكم الاستئناف وليس لمحاكم الاستئناف التجارية لعدة اعتبارات نورد البعض منها بشكل مختصر :

- فمحاكم الاستئناف هي محاكم الدرجة الثانية في القضايا التي تبت فيها المحاكم الابتدائية أيا كان نوع القضية التي بتت فيها. لأن العبرة بالاختصاص الأصيل الممنوح للمحاكم الابتدائية. أما تدخل محاكم الاستئناف فما هو سوى مسألة تلقائية يفرضها المنطق القانوني. ولو سلمنا بمنح الاختصاص لمحاكم الاستئناف التجارية لقمنا بضرب أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي المغربي والمتمثل في التقاضي على درجتين. وكان من الممكن أن نمنح لمحاكم الاستئناف التجارية هذه الصلاحية لو كانت المحاكم التجارية وهي محاكم أول درجة في المادة التجارية هي التي أصدرت الحكم المطعون فيه،

- من التعديلات التي أدخلها المشرع على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية أن الطعن بالنقض لا يجوز بالنسبة للأحكام الانتهائية التي لا تتجاوز 20000 درهم. وهو تعديل يطرح أكثر من علامة استفهام. هل يقصد المشرع كل القضايا أم يشير ولو بطريقة غير مباشرة إلى القضايا التي تبت فيها المحاكم الابتدائية في المادة التجارية ؟

إن التفكير السريع في هذا التساؤل يفضي إلى قبول الفرضيتين معا لأنه لا يعقل أن نقوم بإخراج القضايا الأخرى والاقتصار على المادة التجارية. لكن التعمق في الأمر يجعلنا نقر أن المشرع يقصد القضايا التجارية التي تنظر فيها

المحاكم الابتدائية أي تلك التي لا تتجاوز 20000 درهم، وذلك لأن هذه القضايا تعد استثناء على القاعدة المعمول بها أمام المحاكم التجارية والتي تكمن في أن كل النزاعات التي تبت فيها هذه الأخيرة لا تكون انتهائية وإنما تقبل الاستئناف،هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك مبدأ متعارف عليه في المادة المدنية وهو أن القضايا التي تتجاوز 3000 درهم تقبل الطعن بالاستئناف، أي أن تلك التي لا تتجاوز هذا المبلغ تكون الأحكام الصادرة بخصوصها انتهائية. فلو لم يقصد المشرع القضايا التجارية لوقعنا في التضارب والاجترار أن 3000 درهم كافية حتى يكون الحكم انتهائيا بالنظر إلى كون قيمة القضايا المدنية زهيدة مقارنة مع القضايا التجارية.

مما سبق، يمكن القول إن توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية يثير عدة إشكالات غالبا ما تنعكس على حقوق المتقاضين. وعليه من المستحسن أن يعيد المشرع النظر في القواعد والأحكام التي ينص عليها في مجال الاختصاص تلافيا للنتائج السلبية التي قد تترتب على المقتضيات السارية المفعول حاليا، والله الموفق والمستعان.